

1510562-91.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510562-91.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510562-91.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2119420/2020 - 26º D.P. SACOMA, 11416638 - 26º D.P. SACOMA, 2140/20/226 - 26º

D.P. SACOMA, 2119420 - 26º D.P. SACOMA, 2140/20/226 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATA ERIC SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

JHONATA ERIC SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06. Isso porque, no dia 14 de maio de 2020, por volta das 22h45min, na Rua Jose Pereira Cruz, 209, Sacomã, nesta Capital, o acusado, agindo em concurso e envolvendo o menor Lucas de Souza Coimbra, trazia consigo para venda, 59 (cinquenta e nove) invólucros da substância TETRAHIDROCANNABINOL, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, destinada ao consumo de terceiros, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que JHONATA se encontrava no local acima indicado, ao lado do menor Lucas de Souza Coimbra, para que, juntos, praticassem o tráfico de drogas. O acusado trazia consigo as porções de maconha no interior de uma sacola plástica, e o menor trazia consigo três porções da mesma droga, todas destinadas à venda. Policiais Militares em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de tráfico de drogas, notaram que o acusado e o menor agiam de forma que consideraram suspeita e perceberam quando o acusado buscou se esconder atrás de um veículo estacionado, ao notar suas presenças. O denunciado e o menor foram abordados e revistados, sendo encontradas as três porções de maconha em poder do segundo. Em posse do acusado nada foi localizado, no entanto, ele próprio admitiu ter dispensado uma sacola com os entorpecentes. A sacola foi encontrada ao lado de JHONATA, e em seu interior os policiais encontraram as 59 porções de maconha.

Informalmente, o acusado admitiu que ele e o menor iriam vender os entorpecentes apreendidos. Durante o interrogatório na delegacia de polícia, o acusado apresentou singela negativa dos fatos.

Oferecida a denúncia de fls. 01/03, foi ela recebida. Consequentemente, o acusado foi citado (fls. 109), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 114/116). Inviável a absolvição sumária, designei audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 2022 (fls. 128/131).

Durante a instrução de causa, foram ouvidos dois policiais, tendo o réu sido interrogado ao final.

Encerrada a instrução criminal e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, manifestaram-se as partes, tendo o Ministério Público requerido a condenação do acusado nos termos da denúncia e não se opõe, dada as circunstâncias dos fatos, da aplicação do redutor e regime aberto.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, desclassificação para artigo 28 da Lei de Drogas e por fim aplicação do redutor. Regime aberto, substituição e recurso em liberdade.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 06/08); o auto de prisão em flagrante (fls. 04/05); bem como as folhas de antecedentes do acusado (fls. 36; 37; 38; 97).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls.13) e dos laudos de constatação provisória (fls.33/35), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls.154/156), com resultados positivos para TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva, senão vejamos.

Policial Gilvan reconheceu o acusado de uma ocorrência de tráfico de entorpecentes. Estavam em patrulhamento em local conhecido por tráfico quando o réu e um menor se escondeu atrás de um veículo. Com o menor localizou 3 unidades de maconha. Com o réu nada foi localizado, mas durante a entrevista perguntou por que se escondeu. Ele disse que estava no tráfico de drogas e que havia se livrado de uma sacola de entorpecentes. Não viu o momento em que ele dispensou a sacola. Foi atrás do veículo e lá encontrou a sacola. Encontrou o entorpecente onde ele se encontrava antes de se esconder. Um Honda Fit Prata. Os fatos ocorreram por volta das 22h40min. Não sabe informar se ele reside nas proximidades. O local era iluminado normalmente. Ao lado dos veículos estavam apenas os dois. Não viu o réu vendendo drogas. Não o conhecia anteriormente. Durante a entrevista os dois confessaram a prática de tráfico de drogas.

Já o policial Gabriel reconheceu o acusado de uma ocorrência de tráfico de drogas apresentado no 26 DP. Estava em patrulhamento ostensivo e passou no local que era

conhecido como ponto de tráfico e viu Jhonatan se escondendo atrás de um veículo ele estava com outro rapaz. Essa atitude motivou a abordagem. Não tentaram fugir. No bolso do menor alguns invólucros de maconha. Com Jhonatan nada foi localizado. Depois de abordado, ele informou que havia deixado uma sacola plástica atrás do veículo onde ele se escondeu e ali a testemunha encontrou uma sacola plástica com maconha. De cabeça não tem certeza, mas depois de verificar o B0 viu tratar-se de 59 invólucros. Os dois admitiram que estavam no tráfico. A sacola estava localizada no chão, embaixo do carro, no ponto que ele se escondeu. Os fatos ocorreram a noite, mas não se recorda exatamente que horas. Não se recorda se as porções encontradas com o menor eram similares as drogas apreendidas na sacola. Não presenciou qualquer contato entre o acusado e outras pessoas. O menor confessou que estava traficando junto com o Jhonata. Pessoas que por ali passavam e que testemunharam os fatos não foram conduzidas porque não é procedimento. Não viu a sacola nas mãos antes dele fugir e não o viu dispensando o entorpecente. Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Lucas, o menor que foi apreendido em companhia do acusado, declarou que tem 17 anos idade. Conhece Jhonata que é seu primo. Estava com Jhonata. Fazia uso de maconha. Ao chegar lá para comprar, atrás de um carro, o traficante acabou jogando a droga embaixo do carro. Tinha comprado a droga do traficante. Andava muito com o primo. Fumava maconha junto com o primo. A mãe do declarante chegou na delegacia depois que prestou depoimento e acha que ela não leu. Admitiu tráfico na delegacia porque ficou com medo do primo ficar preso, ele já tem filhos. Os policiais militares estavam junto na hora que prestou depoimento junto ao Delegado. Achou que ao assumir tudo, nada aconteceria com o réu. Para o Juiz da Infância, disse a verdade, ou seja, a mesma coisa que disse hoje. Os policiais presenciaram o traficante fugir. Não conhecia os policiais. Quando o réu foi ouvido na delegacia, ele disse que somente estaria ali para usar maconha. Foram ameaçados pelos policiais. E na mesma linha, foi o interrogatório do acusado, que negou os fatos e trouxe versão esdruxula a qual, evidentemente não será aceita por este juízo.

Com efeito, Jhonata declarou que foi forjado pelos policiais e que em momento algum declarou que o entorpecente lhe pertencia. Disse que estava ali apenas para comprar drogas junto com seu primo menor, que era quem estava com dinheiro.

Vejamos o inteiro teor de seu depoimento:

Jhonata tem 24 anos de idade. Mora com a mãe e irmã. Trabalha com colocação de

mármore, por conta. Depois que atingiu a maioridade, nunca foi processado. Tem três filhos menores. Não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Não conhecia os policiais. Estava com o primo por ocasião dos fatos. Tinha ido no local para comprar entorpecente. Fuma maconha desde os 15 anos. Reconhece que o entorpecente foi localizado embaixo do veículo. Não estava escondido atrás do carro. Na hora que os policiais chegaram todos correram, ou seja, o traficante e um outro rapaz que estava comprando. Todos conheciam o local, mas o interrogando não. Era a primeira vez que foi ao local comprar droga. Resolveram sair andando e quando foram colocados de frente para a rua, encostados na parede. Passaram a procurar e encontraram a droga no local. Não admitiu em momento algum que estava ali vendendo drogas com o primo. Não se escondeu atrás do carro. Foi abordado uns três ou quatro metros do carro. Lucas já tinha comprado a droga. O delegado de polícia ouviu o interrogando em uma área aberta na delegacia e não em uma sala. Nesse dia não comprou drogas. O dinheiro era do Lucas. Acredita que ele confessou porque ainda era imaturo. Foi ameaçado pelos policiais inclusive na delegacia. Até chegar na delegacia, os policiais disseram que o interrogando seria apenas testemunha. Os policiais ameaçaram o interrogando que iriam destruir a vida do interrogando. Eles disseram que era para o interrogando dizer que ele teria visto os policiais encontrando a droga. Parou de usar droga desde os fatos.

Inicialmente, independentemente da alegação da Defesa, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em depoimentos prestados por policiais, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em alguns depoimentos prestados por policiais, a rejeição de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social.

A suspeita decorre do comportamento apurado no processo e não da mera condição destas pessoas, até porque não existe no Ordenamento Jurídico Pátrio qualquer restrição em relação à validade de depoimentos de policiais além do que não está provada, cientificamente, qualquer tendência destas pessoas faltarem com a verdade. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado.

No caso em apreço, os policiais foram verdadeiros tanto que não disseram que o entorpecente foi visto nas mãos do réu. E se quisessem a certeza de uma condenação, era o que teriam dito. Mas eles disseram que encontraram o entorpecente embaixo do carro, exatamente onde o réu e o menor se esconderam. Além do que, não disseram terem visto o réu em plena atividade de traficância. Disseram que o que chamou a atenção de ambos foi o fato de terem percebido que o réu e seu primo menor, ao perceberem a viatura policial, se esconderam atrás do carro. É evidente que não estão na intenção de prejudicar o acusado, pessoa que sequer conheciam.

De outra parte, fica bem claro as contradições existentes no depoimento do réu, o qual disse que foi ameaçado por eles para que prestassem depoimento como testemunha apenas para dizer que presenciou os policiais encontrarem o entorpecente, fato que o réu admitiu que realmente presenciou.

Outro ponto, diz respeito a confissão de Lucas, o menor, ainda em fase policial. Ele disse que confessou para proteger o primo maior, o que não é verdade porque se assim fosse teria dito que todo o entorpecente lhe pertencia e que o réu não estava traficando. Contudo, limitou-se a confessar a prática do tráfico sem isentar o réu que, por sua vez, negou os fatos, prova de que não foi coagido a nada.

E mais, evidentemente que os policiais não puderam trazer testemunhas já que estavam em dois, em local conhecido por ser ponto de venda de entorpecente. Em primeiro lugar, eles tem que zelar pela própria segurança o que implica em afirmar que não poderiam soltar o réu preso em flagrante e o menor apreendido para o fim de

irem atrás de testemunhas dos fatos, o que colocaria em risco suas integridades físicas. Em segundo, é obvio ululante que ninguém se propõe a depor contra pessoas ligadas ao trafico por motivos notórios, no caso, a Lei do Silencio. Superadas as questões trazidas pela Defesa, e confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal.

Em segunda fase, nada a considerar.

Em terceira fase, afasto a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40, VI da Lei de Drogas porque entendo que a probva não autoriza seu reconhecimento. No mais, nos termos das ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls. 102. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguindo-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstancias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a pratica delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j.

06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno JHONATA ERIC SANTOS, RG: 52.980.096, nascido em 25/09/1997, natural de São Bernardo do Campo - SP, filho de RENATA RODRIGUES GUEDES, como incurso nas sanções do art. 33, "caput" e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição, ou seja, suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; Transitada esta em julgado tornem concluso para a designação de data para audiência admonitória. Sentença publicada em audiência.

São Paulo, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA